

1500932-07.2022.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/08/2022

... admitiu que efetivamente praticava o tráfico na ocasião e foi o responsável por indicar a existência de mais droga na caixa de correio. Não bastasse, o réu estava em local muito conhecido pela prática do tráfico, trazia consigo dinheiro trocado, além de já ter respondido pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico, conforme ele próprio admitiu e está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -
cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500932-07.2022.8.26.0530

Controle: 2022/000867

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2102895/2022 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 24306130 - DEL.SEC.SERTÃOZINHO PLANTÃO, 2102895 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KAUÃ LEONARDO FEITOSA ANGELOTTO

Aos 08 dias do mês de agosto de 2022, às 16:00 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. FLÁVIO JOSÉ DA COSTA; o réu Kauã Leonardo Feitosa Angelotto, sua Defensora nomeada, Dra. MICHELE MARIA MIRANDA FERREIRA (OAB/SP 161120); COMPARECERAM presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Militares David Macedo Novaes e Rodolfo Goulart Costa e a testemunha arrolada pela Defesa Adrielle Silva de Carvalho. Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação Policiais Militares David Macedo Novaes e Rodolfo Goulart Costa e a testemunha arrolada pela Defesa Adrielle Silva de Carvalho, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações,

declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu Kauã Leonardo Feitosa Angelotto, pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e à Dra. Defensora, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

Vistos.

KAUÃ LEONARDO FEITOSA ANGELOTTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de abril de 2022, por volta das 21h30min, na Avenida Presidente Castelo Branco nº 1770, Parque Moggi, na cidade de Barrinha, comarca de Sertãozinho, trazia consigo e mantinha em depósito aproximadamente 15,73g (quinze gramas e setenta e três decigramas), da droga vulgarmente conhecida como maconha, acondicionados em 12 (doze) invólucros tipo "trouxinhas de papel", e aproximadamente 38,21g (trinta e oito gramas e vinte e um decigramas) de cocaína, acondicionados em 30 (trinta) invólucros plásticos, do tipo "eppendorf", conforme auto de constatação preliminar de fls. 04/05 e auto de exibição e apreensão de fls. 06/07, para fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a denúncia, na data dos fatos, KAUÃ praticava o tráfico de drogas nesta cidade de Sertãozinho. No exercício da atividade ilícita, o acusado trazia parte dos entorpecentes com ele, além de manter parte da droga escondida nas proximidades, todos embalados e prontos para a comercialização. Ocorre que Policiais Militares receberam denúncia anônima da atividade criminosa do acusado e dirigiram-se ao local indicado. Lá estando, avistaram KAUÃ e decidiram abordá-lo. Em revista pessoal, os policiais encontraram em sua posse 10 (dez) cápsulas contendo cocaína, além da quantia de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ato seguinte, os agentes policiais revistaram uma caixa de correios que se encontrava ao lado do acusado e, em seu interior, encontraram mais 20 (vinte) porções de cocaína, além de 12 (doze) porções de maconha. Informalmente, KAUÃ confirmou a prática da traficância, assim como a posse e a propriedade da droga. Assim, diante das circunstâncias e do local da abordagem, com a apreensão de quantidade expressiva e variedade de drogas, além da quantia em dinheiro e do depoimento dos policiais militares, restou demonstrada a destinação à venda dos entorpecentes. A denúncia foi recebida em 20 de maio de 2022 (fls. 84/85), o réu foi citado (fls. 107) e apresentou resposta à acusação (fls. 114/115). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado requereu a desclassificação do delito para aquele do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, pugnou pela fixação de penas mínimas, o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e do tráfico privilegiado.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 28/30), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09/10), pelas imagens fotográficas (fls. 23 e 25), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 94/105), conclusivos por se tratar de maconha e cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também é certa e repousa sobre o acusado.

Os policiais militares, David e Rodolfo, tanto na fase policial quanto em Juízo, disseram que receberam denúncia anônima sobre um indivíduo utilizando camisa do Corinthians que estava no local do delito comercializando substâncias entorpecentes. Por conseguinte, para lá se dirigiram, a fim de averiguar o fato. Ao chegarem no local, o indivíduo foi identificado como KAUÃ e estava vestindo camisa do

Corinthians. Revistado, em sua posse (em meio as vestes) foram encontradas 10 (dez) cápsulas plásticas do tipo "eppendorf" contendo a substância entorpecente vulgarmente denominada "cocaína" e o valor em dinheiro de R\$ 50,00 (cinquenta reais). Ainda, em revista a uma caixa de correios que se encontrava ao lado do acusado, indicada pelo próprio acusado, foram encontradas outras 20 (vinte) cápsulas do tipo "eppendorfs" contendo a mesma substância entorpecente "cocaína", além de 12 (doze) "trouxinhas" contendo a erva "maconha". Inquirido sobre o fato, KAUÃ admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos, reconhecendo que havia escondido parte das drogas na caixa dos correios e revelando que se destinavam ao comércio ilegal. Isto posto, foi conduzido até o presente Plantão de Polícia Judiciária, onde a Autoridade Policial determinou fosse elaborado o Auto de Prisão em Flagrante Delito, formalizando sua custódia (fls. 11/13 e mídia).

A testemunha Adrielle, arrolada pela Defesa, disse ser namorada do réu e que presenciou a abordagem e prisão do réu. Disse que o réu, após receber um vale de R\$ 150,00 do patrão, foram na biqueira onde o réu comprou 10 pinos para uso próprio. Quando da abordagem, os "meninos" saíram correndo e somente o réu foi abordado. Os policiais também encontraram droga que estava escondida numa caixinha de correio na casa dos "meninos" quando o réu já estava detido, dentro da viatura. Caua admitiu a propriedade da droga apenas que a depoente fosse liberada (v. mídia).

O réu, interrogado na fase policial, permaneceu em silêncio (fls. 06).

Em Juízo, o réu negou a acusação. Alega que devia R\$ 50,00 para os "meninos" da biqueira, motivo pelo qual pediu um vale de R\$ 150,00, pagou sua dívida e comprou mais droga para uso próprio. Após comprar a droga os policiais se aproximaram, os "meninos" fugiram mas o interrogando não correu. Após detido é que os policiais passaram procurar e encontraram a droga que estava na caixinha do correio. Na ocasião realmente vestia uma camisa do Corinthians. Somente admitiu a propriedade de toda a droga encontrada para que sua namorada fosse liberada. Admitiu ainda que já respondeu pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, cumprindo medida de liberdade assistida (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário das drogas apreendidas, as quais se destinariam à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais militares, foi recebida denúncia anônima dando conta de que no local dos fatos pessoa que usava camisa do Corinthians praticava o tráfico de drogas.

Em diligências, os agentes identificaram KAUÃ, que usava uma camisa do Corinthians e, em sua posse, foram encontradas 10 (dez) cápsulas de cocaína, bem como a quantia de R\$50,00 (cinquenta) reais em espécie. Além disso, em revista a uma caixa de correios que se encontrava ao lado do acusado, foram identificadas outras 20 (vinte) cápsulas de cocaína e 12 (doze) trouxinhas de maconha, todas embaladas e prontas para comercialização. Por fim, inquirido, KAUÃ confessou a propriedade dos entorpecentes e o tráfico de drogas no local, bem como foi ele mesmo quem indicou que havia mais droga na caixa de correio.

O réu, por sua vez, negou a prática delitativa, alegando ser de sua propriedade apenas as porções de cocaína que estavam em sua posse, e que seriam destinadas ao uso próprio.

Porém, sua versão não convence e ficou isolada nos autos, sendo certo que o relato da amásia do réu não pode prevalecer frente aos depoimentos do policiais, notadamente por inexistir qualquer indício de que tivessem a intenção de prejudicar o réu.

Com efeito, além de o réu usar camisa do Corinthians, da forma como indicada na denúncia anônima como sendo o traje do traficante, os policiais afirmaram que nenhuma outra pessoa do sexo masculino estava no local e que o réu ainda admitiu que efetivamente praticava o tráfico na ocasião e foi o responsável por indicar a existência de mais droga na caixa de correio. Não bastasse, o réu estava em local muito conhecido pela prática do tráfico, trazia consigo dinheiro trocado, além de

já ter respondido pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico, conforme ele próprio admitiu e está comprovado a fls. 34.

Portanto, por todos os motivos referidos, conclui-se que as drogas apreendidas efetivamente eram destinadas ao tráfico.

No mais, a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova pericial já citada, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que os tivessem a intenção de prejudicar o acusado. Neste sentido:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de milicianos para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos: “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

Assim é que não se contesta a validade dos dois depoimentos acima delineados, que constituem prova é perfeitamente aceitável.

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares – Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Tráfico caracterizado – Condenação mantida – PENA – redutor no patamar máximo – necessidade – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 – Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves – d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO.

INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP – Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 – Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira – d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA ORAL INCRIMINADORA – A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA – RECURSO

DESPROVIDO. (TJSP - APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 - Relator(a)

Desembargador(a) Euvaldo Chaib - d.j. 14.11.2017).

"PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14a Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16a Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9a Câmara do 5o Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, de rigor o reconhecimento da menoridade relativa do agente. No entanto, tal circunstância não tem o poder de fazer com que a pena seja reduzida abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, reputo incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Tal benesse deve ser concedida apenas aos agentes primários, de bons antecedentes, e que não se dediquem a atividades criminosas e nem integrem organização criminosa.

Porém, no presente caso, o réu já respondeu pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico junto à Vara da Infância e Juventude (v. fls. 34), conforme ele próprio admitiu quando interrogado em Juízo, sendo-lhe aplicada medida de liberdade assistida.

O réu ainda foi flagrado comercializando significativa quantidade de droga, como já mencionado. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva da drogas encontrada com o réu (Cocaína).

O réu, ademais, foi encontrado em região onde a traficância é estruturada e se desenvolve de forma endêmica, indicando que claramente se incorporou à organização criminosa, ou, no mínimo, que tem se dedicado frequentemente à traficância, além de que o acusado não comprovou nos autos, com segurança, o exercício de qualquer atividade remunerada lícita.

Por todos referidos motivos, o réu não pode ser considerado mero traficante eventual ou se sustentar que não se dedica a atividades criminosas.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito "erga omnes", cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante "o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, além de a penalidade imposta impedir, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime, bem como conveniente e adequada a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao réu, nos termos do artigo 33, § 1º, "a" c.c. artigo 33, § 3º, do Código Penal.

Inicialmente observo que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente são, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Não bastasse, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código e, especificamente em relação aos crimes previstos na Lei de Drogas, deve-se ter em conta ainda as regras previstas nos artigos 42 e 43 da Lei 11.343/06, que determinam sejam consideradas, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

A propósito, ressalto que o acusado estava na posse de significativa quantidade de droga e já respondeu pela prática de ato infracional equiparado a tráfico. Destaco ainda a natureza de alta potencialidade lesiva da droga encontrada com o réu (cocaína).

E também pelos mesmos motivos que justificaram a fixação do regime inicial fechado e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, ainda mais porque permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, nada justificando a soltura após a condenação.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu KAUÃ LEONARDO FEITOSA ANGELOTTO, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pelo Réu e sua Dra. Defensora foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. EXPEÇA-SE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA URGENTE. Arbitro honorários advocatícios à Defensora nomeada em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu,_____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.